

1500277-10.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... contradições. Na delegacia, o réu confessou o tráfico, assumindo ser dono de parte da droga (a que foi encontrada com ele), mas em juízo, alterou a versão e passou negar toda a propriedade da droga, dizendo que toda a droga era de terceiro e que guardava a droga e praticava o tráfico em troca de uma dívida de droga com terceira pessoa de nome Zoio.

Apesar das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500277-10.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500277-10.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041281/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 22991126 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2041281 - 01º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRIAN PATRICIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1500277-10.2022.8.26.0603 (Controle nº 379/2022)

VISTOS.

BRIAN PATRICIO, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi preso em flagrante,

denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 23h00min, na Rua Umberto Vignardi, nº 350, Quemil, nesta cidade e comarca de Birigui, trazia consigo e tinha em depósito 30 (trinta) eppendorfs de cocaína, pesando um total de 36,15 gramas, e, bem como 115 (cento e quinze) porções de cocaína, sob a forma de crack, pesando 35,96 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 128/139.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 112), cuja peça foi juntada às fls. 144/150, sobrevindo o recebimento da denúncia em 25 de julho de 2022 (fls. 154/155) e a citação do acusado (fl. 171).

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas em comum, sobrevindo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 177/178).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 182/187).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o artigo 28 da lei de drogas. Em caso de condenação, pleiteou seja aplicada a pena no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa; a redução da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06; o direito de o acusado de apelar em liberdade; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo (fls. 190/198).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o boletim de ocorrência (fls. 06/09); a nota de culpa (fl. 22); o auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); o relatório policial (fls. 86); os laudos de constatação prévia (fls. 12/15); os laudos periciais (fls. 74/76, 77/80, 81/85 e 128/13); o depósito judicial (fl. 72); os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia, o acusado confessou que estava vendendo cocaína há cerca de 01 mês, porém tinha apenas dois pinos de cocaína na sua casa. Não havia nenhuma droga no momento da abordagem. Negou que qualquer "pedra" de crack apresentada era sua, assim como negou possuir rolo de plástico filme e balança eletrônica. Quanto aos sacos de microtubos vazios e o dinheiro apresentado, disse que estavam na sua casa (fls. 03).

Em juízo, alterou sua versão, confessando que todos os entorpecentes apreendidos pertenciam a um traficante conhecido como "Zóio", o qual o ameaçou para guardar e vender as drogas em troca de sua dívida de drogas (fls. 177/178).

Como se vê, o acusado, na delegacia, confessou que comercializava droga, e em juízo, afirmou que guardava as drogas para terceiro, que era traficante.

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Anoto que, apesar da confissão em ambas as fases da persecução penal, o réu apresentou contradições. Na delegacia, o réu confessou o tráfico, assumindo ser dono de parte da droga (a que foi encontrada com ele), mas em juízo, alterou a versão e passou negar toda a propriedade da droga, dizendo que toda a droga era de

terceiro e que guardava a droga e praticava o tráfico em troca de uma dívida de droga com terceira pessoa de nome Zoio.

Apesar das contradições, quer acolhida uma versão, quer acolhida outra, o crime de tráfico restou caracterizado, como se verá adiante.

Com efeito, as testemunhas Denilson Pereira da Silva e Márcia Marli Bezerra, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, relataram que receberam denúncia de disparo de arma de fogo. Dirigiram até o local, avistaram um rapaz, que se assustou com a presença ao vê-los e tentou evadir-se. Abordaram e não foi encontrado nenhum armamento. No entanto, localizaram 15 (quinze) porções de crack, 10 (dez) porções de cocaína, 01 (um) aparelho celular, e R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) nos bolsos do acusado. O acusado confessou que comercializava os entorpecentes, franqueou a entrada no imóvel, e indicou onde havia mais drogas, sendo encontrados mais 100 (cem) porções de crack, 20 (vinte) microtubos de cocaína, R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) em notas diversas, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) balança de precisão (fls. 02, 04 e 177/178).

Os policiais foram categóricos em afirmar que o acusado confessou a prática do tráfico. Logo, no caso concreto e levando em conta os demais elementos de prova existentes nestes autos, evidencia-se, com segurança, que o réu incidiu na prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

Ainda quanto aos policiais militares, é cediço que o valor de seus depoimentos testemunhais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Note-se, ainda, que o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade, logo, estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há motivo para desprezá-los, apenas por se tratar de policiais.

Quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se, ainda:

“Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação, ou tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Procedente” (STF - 2a T. - HC n.º 74.522-9/AC - Rel. Min. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).”

“Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Por tudo que foi exposto quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há o que se questionar quanto as suas declarações.

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consiste realmente em "cocaína" e "crack" (exames químicos-toxicológicos de fls. 128/139).

De outra parte, os entorpecentes apreendidos, ou seja, 36,15 gramas de cocaína e 35,96 gramas de crack; as circunstâncias da abordagem do réu (tentou se evadir ao avistar os policiais militares), a forma de acondicionamento das drogas (distribuídas em porções prontas para comércio); a apreensão de dinheiro (R\$ 561,00), balança de precisão, eppendorfs vazios, plástico filme e celular; e a confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal, estão a caracterizar a traficância.

No caso, não se pode olvidar que foram apreendidas balança de precisão e eppendorfs vazios, juntamente com as drogas, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, estes apetrechos são utilizados para quantificar e embalar as porções que serão vendidas.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga e tenha em depósito para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembre-se que o réu foi denunciado por trazer consigo e ter em depósito as drogas.

Importante anotar, outrossim, que o simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita e, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes.

Lembre-se de que o réu, em juízo, afirmou que estava guardando e comercializando as drogas para um traficante de apelido "Zóio", o que só vem confirmar a prática do tráfico de drogas, cuja prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria por parte do réu, no crime ora apurado.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo e tinha em depósito 30 (trinta) eppendorfs de cocaína, pesando 36,15 gramas, e 115 (cento e quinze) porções de crack, pesando 35,96 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Tanto é assim que, em juízo, o réu disse que guardava a droga para um traficante, em troca do pagamento de uma dívida de droga que tinha com ele. Descabida, portanto, a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei de Drogas.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado não ostenta maus antecedentes e as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão e menoridade penal relativa, mas deixo de reduzir a pena, pois já estabelecida em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento de pena, no entanto, estão preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, haja vista que o réu é primário, não ostenta maus antecedentes, além do que não há provas dando conta de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, reduzo as penas em 1/3 (um terço), resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

A redução está sendo aplicada no mínimo em razão da quantidade da droga e, nestas condições, deve haver diferenciação no momento da aplicação de causa de diminuição de pena.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Neste ponto, anoto que a imposição coletiva vinculante quanto à vedação de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos condenados pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, determinada pelo voto monocrático do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ª Turma do C. STJ) em sede de HC nº 596.603/SP, foi cassada pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, no julgamento do RE nº 1.344.374, em 01/12/2021, conferindo ao julgador a liberdade de avaliar o regime prisional cabível em cada caso.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Neste ponto, anoto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que inexistente previsão legal para a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa.

Ademais, cabe consignar que a pena de multa é uma modalidade de reprimenda cominada à infração penal, sendo vedada a sua exclusão, sob pena de o pedido de isenção formulado pelo sentenciado se transmutar em supedâneo recursal, o que, em hipótese alguma, se pode admitir.

Descabida, portanto, a pretensão da defesa técnica quanto ao não pagamento da multa imposta ao réu.

Quanto ao pedido relativo à dispensa das custas processuais, o mesmo não comporta acolhimento, pelos mesmos motivos já expostos acima, lembrando que, recentemente, o Tribunal de Justiça editou ato normativo aos juízes, para que se empenhem na cobrança das custas processuais devidas em processos criminais, nos termos do que

determinam as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR BRIAN PATRÍCIO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 13/02/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal). Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por

essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (destrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 40/42), ocasião em que foram expostos

os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais ficam aqui reiterados, como razão de decidir.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada (fls. 127 e 140 e 141), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Restou provada a procedência ilícita do dinheiro apreendido às fls. 10/11 (R\$ 561,00), razão pela qual não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente. Logo, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro depositado à fl. 72.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado (dinheiro), instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos objetos apreendidos (rolo de plástico filme, balança de precisão e eppendorfs vazios), apesar de serem instrumentos do tráfico de drogas praticado pelo acusado, diante das suas naturezas, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro e destruição do objeto, instruindo-se o ofício com as cópias mencionadas no parágrafo anterior.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA